

CCC Trab. y CA, Villa Dolores, Cba. 28/3/2022. Sentencia Nº 13. Trib. de origen: Juzg. 1º. CC Concil., Fam. Contr., Niñez, Penal Juv. y Faltas, Villa Cura Brochero, Cba. " do - Acción Posesoria - Expte. Nº 2705007".

2ª Instancia.

Villa Dolores, Córdoba, 28 de marzo de 2022 1 - ¿Procede el recurso de apelación planteado por el demandado y en su caso, qué resolución corresponde dictar? En los autos caratulados (...), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Penal Juvenil y Faltas de Villa Cura Brochero, en los que mediante sentencia nº 103 de fecha 20/11/2020 se resolvió: "1º) Rechazar la excepción de falta de acción o falta de legitimación activa deducida por el demandado. 2º) Hacer lugar a la acción posesoria de despojo entablada por el Sr. Juan José Resce y, en consecuencia, condenar al demandado, Sr. Daniel Alberto Resce, a restituir al actor el inmueble ubicado en calle Intendente Oviedo Nº 1402/3 de Mina Clavero, Dpto. San Alberto de esta Provincia y que se describe como una fracción de terreno de 1583 mts.2, aproximadamente, en el plazo de diez días de quedar firme la presente resolución, libre de personas y/o cosas puestas por él o que de él dependan, bajo de apercibimiento de cumplir dicha manda con el uso de la fuerza pública. 2º) Imponer las costas del presente proceso a cargo del demandado vencido. 3º) [Omissis]." El doctor Facundo Daniel Gil dijo: I. En contra de la sentencia cuya parte resolutive se ha transcripto, el demandado Sr. Daniel Alberto Resce deduce recurso de apelación. Concedido, radicada la causa en esta instancia de grado e impreso el trámite de rigor – proveído de fecha 3/3/2021–, el apelante expresa agravios con fecha 17/3/2021, que son contestados por el actor apelado con fecha 7/4/2021. Dictado el decreto de autos con fecha 8/4/2021 pasan los presentes a resolver. II. El pronunciamiento adverso a sus intereses motiva los agravios del apelante, los que admiten el siguiente extracto: Cuestiona la valoración de la prueba testimonial rendida en el proceso. Inicia la crítica sosteniendo que el tribunal de primera instancia ha cometido errores de interpretación de lógica racional y jurídica al momento de valorar y analizar la prueba, lo que ha conducido al dictado de una sentencia con graves defectos. Ataca la conclusión sentencial que refiere a que de los testimonios acompañados por el demandado no surge con claridad si habitaba el inmueble previo al momento del despojo y que si bien no se encuentra obligado a ello, frente a esa incertidumbre cobran fuerza los testimonios aportados por el demandante en cuanto a que el mismo poseía la fracción en el momento inmediato anterior a que sucediera el hecho denunciado. Cuestiona que el a quo haya utilizado como razonamiento neurálgico de su sentencia el testimonio del Sr. Cristian Ricardo Chacón -fs. 92- cuya audiencia testimonial fue dejada sin efecto mediante el proveído de fs. 102 a instancias del pedido de nulidad de su parte. Postula que aun así el tribunal ha valorado dicho testimonio. Destaca que el actor nunca más volvió a instar la audiencia testimonial del Sr. Chacón pese a que fue proveída en el mismo decreto que dejó sin efecto la audiencia de fs. 92. Denuncia que el juzgador realiza un análisis parcializado del testimonio del Sr. José Eduardo Amaya preguntándose cómo es posible que pueda concluirse que no existe prueba de que el demandado en los meses de septiembre y octubre de 2015 se encontraba en posesión de la cosa, siendo que el testigo reconoció trabajar como albañil a sus órdenes en dichos meses en el inmueble objeto de la acción. Cuestiona que los testigos aportados por su parte, Sres. Cuadrelli, Cáceres, El Ain y Amaya han sido objeto de una particular valoración por parte del juzgador. En esa línea critica la conclusión sentencial que

sostiene que de los testimonios en cuestión no surge con claridad si habitaba el inmueble previo al momento del despojo siendo que, a su entender, los dichos de aquellos sí avalan tal extremo. Incluso, la testimonial del Sr. Amaya, quien dijo haber estado trabajando en los meses de septiembre y octubre de 2015 en el inmueble objeto del pleito por lo que está más que probado el corpus y el ánimo por su parte. Con relación con los testimonios de los señores Quinteros y Lera, aportados por el actor, sostiene que carecen de relevancia probatoria ya que se limitan a declarar que el demandado vivía temporalmente en la vivienda de calle Santa Rita, ya que su casa en calle Intendente Oviedo estaba siendo reparada por trabajos de albañilería. Nuevamente hace presente que el testimonio del Sr. Chacón fue declarado nulo en autos. Cuestiona asimismo que no se haya valorado la prueba documental aportada por su parte, la que aunque sea de manera indiciaria demostraba su posesión. Entiende que el a quo debió haber integrado dicha prueba con el resto del material probatorio obrante en la causa y realizar un proceso lógico deductivo. Se queja igualmente de que la prueba documental ofrecida por su parte no haya sido tomada en cuenta y sí lo haya sido la que acompañó el actor, tal la cesión de boleto de compraventa de fs. 9/10. Postula asimismo que su parte tenía una relación de poder con el inmueble, tanto en corpus como en animus posesorio porque la prueba así lo indica. Pero si aún quedaran dudas al respecto, entiende debió haberse aplicado lo preceptuado por el art. 2243 del CCCN, ya que es claro que su parte era quien se encontraba más próxima de la cosa a la fecha de la lesión y quien la poseía con más antigüedad. Por último sostiene que el actor nunca estuvo en posesión del inmueble, al punto tal que la única prueba que pretendió erigirse como basamento de ello carece de efectos jurídicos, tal el testimonio del Sr. Chacón en contrapartida con los dichos del testigo Amaya, quien declaró haber trabajado en los meses de septiembre y octubre del 2015 en el predio por indicaciones de su parte.

III. El actor, en ocasión de contestar los agravios del demandado, sostiene que el decreto de fecha 15/5/2028 [sic] no resolvió la nulidad articulada por el apelante y lo hace con cita del art. 383 del CCCN. Postula que la categoría "dejar sin efecto" no existe en términos procesales en virtud de que se está ante un acto procesal nulo o válido y, por ende, al no haberse insistido en que se declare la nulidad por parte del recurrente en la ocasión procesal válida, ello no se puede subsanar por vía de apelación. Entiende así que la testimonial del Sr. Chacón sí es un elemento probatorio válido para la solución de la causa, más allá de apuntar que no es el único. Con relación con las quejas vertidas en los puntos b) c) y d) del escrito de expresión de agravios, sostiene que se trata de agravios inconducentes que no atacan los razonamientos ni los fundamentos de la resolución bajo embate.

IV. El pronunciamiento recurrido: i) En primer lugar entiende aplicable al caso de autos el Código Civil y Comercial de la Nación en razón de que el actor alega haber sido despojado en octubre de 2015, data en la cual había ya entrado en vigencia dicho cuerpo legal. ii) Con cita de doctrina analiza el sistema estructurado en la nueva normativa fonal con relación al régimen de defensas posesorias. Define al despojo como una acción que tiende a prevenir que los interesados acudan a las vías de hecho para solucionar sus diferencias. Analiza los legitimados activos y pasivos de dicha acción así como también los requisitos para su procedencia. iii) Comienza relacionando las testimoniales de los Sres. Daniel Cuadrelli, Roberto Enrique Cáceres, José Eduardo Amaya y Jorge Alberto El Ain, cuyos testimonios fueran ofrecidos por el demandado. iii.1) Resalta que de los testimonios en cuestión no surge con claridad si el accionado habitaba el inmueble previo al momento del despojo y que si bien no se encontraba obligado a ello, resulte que frente a esa incertidumbre, cobran fuerza los testimonios aportados por el actor en cuanto a

que él poseía el inmueble al momento del despojo. iii.2) En tal orden de ideas comienza citando al testigo Cristian Ricardo Chacón, quien afirma haber visitado la propiedad varias veces durante septiembre de 2015 para alquilársela al actor con la finalidad de poner un lavadero junto con un amigo, que el inmueble estaba cerrado y vacío, no había nadie, había unas máquinas para lavado de autos y un departamento al fondo pero estaba desocupado y que le consta que el inmueble estaba con llave y candado que pertenecían al Sr. Juan José Resce. A dicha testimonial suma las que ubican al demandado viviendo en el barrio Villa Luján de Mina Clavero. Tales los testimonios de Ary Cristian Quinteros y la Sra. Aerolina Lera, locadora del demandado y quien cuando se retiró le dijo "que se iba a cortar una cadena porque iba a regresar a una casa que le habían quitado". Entiende que más allá de la mayor antigüedad en la posesión del inmueble acredita[da] por el Sr. Daniel Resce, en lo que aquí interesa, sostiene demostrado que durante el mes de septiembre y parte de octubre de 2015 el inmueble se encontr[aba] en posesión del actor, quien lo mantenía cerrado con candado y cadena y lo ofreció para alquilar. iv) Define que a título indiciario resulta favorable al actor la cesión del boleto de compraventa celebrado por el padre del actor y del accionado a favor del primero obrante a fs. 9/10. v) Suma a todo ello la circunstancia de que el demandado no vivía en el inmueble sino que con su familia habitaba un inmueble que alquilaba ubicado en barrio Luján de Mina Clavero. Pondera que más allá de que ello haya sido admitido por el accionado, fueron incorporados los recibos de pago de los correspondientes cánones locativos, los que fueran reconocidos por la locadora. vi) Asimismo considera que el hecho del despojo surge de la denuncia por usurpación que formuló el actor en contra del demandado con fecha 16/10/2015. vii) Define que el actor acreditó debidamente la posesión previa al despojo, por lo que no resulta posible aplicar la presunción contenida en el art. 2243, 2º. párrafo del CCCN. Por el contrario, quien se encontraría favorecido sería el actor por la presunción contenida en el primer párrafo de la norma aludida, porque ha acreditado estar en contacto con la cosa en la fecha más próxima a la lesión. Cita doctrina en orden a la aplicación de las presunciones del art. 2243 del CCCN. viii) Concluye que el actor fue desposeído por el demandado del inmueble reclamado, quien lo mantiene en su poder, por lo que corresponde rechazar la defensa de falta de acción o falta de legitimación activa y hacer lugar a la acción de despojo, con costas. V. Ingresando al tratamiento del recurso planteado por el demandado, adelanto mi posición favorable a su procedencia. Doy razones. V.a.) Tal como expuso el juzgador, en la actualidad la cuestión de las acciones posesorias se ha simplificado con relación a la normativa de fondo anterior. El tópico se encuentra regulado en el Capítulo I, del Título XIII del Libro IV del CCCN (arts. 2238 al 2246 inclusive). Existen sólo dos acciones posesorias ya que han desaparecido las llamadas policiales que preveía el régimen derogado. Tenemos una acción de despojo que sirve para los actos de desapoderamiento y una acción de mantener a la cual se recurre cuando hay turbación de la posesión. Asimismo, en cada una de estas dos acciones puede tener cabida la variante de la obra que se comienza a hacer. Cuando se produce el desapoderamiento, definido por el art. 2238 como "cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o al tenedor", éstos cuentan con la acción posesoria de despojo para recuperar el objeto en cuestión, siendo su finalidad la de recuperar la posesión o la tenencia de la cosa perdida; su objeto puede ser una cosa mueble o inmueble o una universalidad de hecho y se puede reclamar toda la cosa o una parte. V.b) Encarando los agravios desarrollados por el apelante nos encontramos en primer lugar con la crítica dirigida a la ponderación que ha hecho el a quo en el resolutorio en crisis respecto del testimonio del Sr.

Cristian Ricardo Chacón ofrecido por la parte actora. Postula que ello nunca debió haber ocurrido en razón de que el acta testimonial de fs. 92 –donde consta la recepción del testimonio– fue dejada sin efecto a pedido de su parte mediante proveído de fecha 15/5/2018 obrante a fs. 102. No puedo sino concluir en el mismo sentido que el apelante, desde que receptada dicha audiencia testimonial, acto seguido, el apoderado del demandado a fs. 93 dedujo planteo de nulidad de la misma aduciendo que nunca fue notificado de su fecha de recepción; circunstancia reconocida expresamente por el apoderado del actor al contestar la vista del pedido de nulidad "...que pese a no estar notificado el abogado patrocinante de la demandada de la audiencia testimonial prevista..." (fs. 98vta.). Con base en ello, el juzgador dictó el proveído de fs. 102 que dispuso: "dejar sin efecto la audiencia celebrada con fecha 9/3/18 (fs. 92)". La discusión que propone el apelado en el sentido de que no se resolvió la nulidad planteada como lo exige el art. 383 del CCCN en razón de que la categoría "dejar sin efecto" no existe procesalmente hablando, como también que el apelante no insistió con la declaración de nulidad solicitada, no deja de ser más que un interesado juego de palabras, una mera logomaquia. Sin perjuicio de que la norma citada por el recurrido al contestar el agravio refiere a la nulidad de tipo sustancial – variante de la ineficacia de un acto jurídico–, aquí se trata de una nulidad procesal y en el entramado de autos "dejar sin efecto" o "declarar la nulidad" de la audiencia testimonial del Sr. Chacón importa lo mismo. La expresión empleada por el juzgador en el proveído de fs. 102, de amplia utilización en el campo jurídico, puede resumirse en la consecuencia de la revocación o anulación de un acto jurídico, como dije, procesal, por lo que el argumento defensivo que ensaya el recurrido resulta inatendible. La mención que éste realiza del decreto de fs. 108 resulta insustancial desde que alude a un pedido de nulidad de las testimoniales de fs. 87 y 88 formulado por el apelante, cuestión ajena al punto tocante a la testimonial del Sr. Chacón. En suma, sin perjuicio de la expresión empleada por el a quo en el proveído de fs. 102, lo cierto y real es que el planteo de nulidad del apelante fue admitido por el juzgador y consentido por la parte actora al ser notificada del mismo -fs. 115- sin formular cuestionamiento alguno. Por ello, el testimonio de Chacón no debió ser valorado en el pronunciamiento bajo recurso. Por lo demás, no resulta ocioso remarcar que en ocasión de contestar la nulidad planteada por el demandado, la parte actora en su escrito de fs. 98/99 solicitó a todo evento la designación de una nueva audiencia a fin de recibir el testimonio de Chacón, lo que fue proveído favorablemente por el tribunal a fs. 102 sin que dicha parte instara la recepción del acto testimonial en cuestión. En definitiva, el testimonio en cuestión no se receptó por la apatía de quien lo propuso. V.c ) Establecido ello, las demás quejas del apelante expuestas en los apartados "A" y "B" de la expresión de agravios nos ubican frente a qué es la posesión y cómo se acredita ésta. La posesión representa una situación o estado de hecho de una persona con respecto a la cosa a la cual la ley asigna una consecuencia jurídica, independiente de la existencia de derechos reales que ligen al sujeto con la res; la posesión es antes que nada una situación fáctica calificada por una intención, que se traduce en el ejercicio efectivo de un derecho real, disfrute, señorío, sobre una cosa a título propio objetivada y exteriorizada en actos que evidencian un ánimo. Según el art. 1909 del CCCN, "Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no". La norma, en cuanto refiere a que una persona tenga "un poder de hecho sobre una cosa", expresa el corpus, y la referencia a "comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no" refiere al animus domini. Entonces, para que se configure la posesión se requiere la concurrencia de

ambos requisitos, el corpus y el animus. El primero consiste en la posibilidad de disponer físicamente de la cosa y no es necesario su ejercicio actual. Alcanza que la persona se encuentre en una determinada relación objetiva con la cosa que, para que la opinión común, aparezca como un poder de hecho sobre ella. Dicha relación debe tener cierta estabilidad, ya que el mero contacto con la cosa o una actuación fugaz y pasajera sobre ella no constituyen posesión. Por su parte, el segundo –elemento subjetivo de la posesión– requiere comportarse como titular de un derecho real, es decir, comportarse con la cosa sin reconocer en otra persona un derecho superior. Este elemento apunta a una intención exteriorizada, es decir, traducida en hechos exteriores. En síntesis, si una persona tiene el corpus y se comporta con la cosa sin reconocer en otro un derecho real, se puede decir que tiene ánimo de dueño y que es poseedora. Se ha dicho que "Ese derecho es la posesión misma, se confunde con ella, a tal punto de que la posesión no existiría en el campo jurídico, si no se reconociera ese derecho [...] Es poseedor quien se comporta respecto de la cosa como propietario o como titular de uno de los derechos reales cuyo ejercicio, según el Código, importa poseer" (Borda, "Tratado de Derecho Civil - Derechos Reales", t. I, págs. 40 y 82). V.c.1) Conviene recordar que la posesión no depende de elementos instrumentales sino que es el ejercicio de una relación de poder que lleva a comportarse con respecto de una cosa como titular de un derecho real que se ejerce materialmente y con ánimo concordante. Asimismo, debe tenerse presente que en el marco de las acciones posesorias la indagación que se realiza no lo es a la hora de alumbrar el ius possidendi (derecho a la posesión) que emerge de la titularidad de derechos reales que se ejercen por posesión –o derecho a éstos–, sino estrictamente a proteger el derecho que exuda de la realidad de la relación misma, el ius possessionis de la propia relación de poder exteriorizada. Es la materialidad de la posesión, con independencia de los títulos o derechos personales de cualquier orden que habiliten a ejercerla u obtenerla lo relevante hay que estar al hecho estrictamente posesorio, en tanto el título no confiere per se la posesión y sólo da - eventualmente- un derecho a ella. Como ya sentara esta Cámara con anterioridad y de modo concordante con la generalidad de la doctrina y jurisprudencia, la posesión se exterioriza y hace pública por hechos y actitudes del hombre con relación a la cosa que inequívocamente evidencien un ánimo, una intención; y tratándose de la exteriorización de hechos relevantes demostrativos de esta situación de señorío, la testimonial será siempre una probanza relevante (vide "Fernández Nita Delfina c/ Miguel Ángel Pérez y Otro - Acción de Manutención", Sent. N° 3, 12/02/07, Abeledo Perrot N° 70041302). Merece ser resaltado que importa un principio inconcuso que la prueba testimonial debe ser valorada en su conjunto y en conjunción con los demás medios producidos, atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de sus declaraciones (cfr. Jorge L. Kielmanovich, "Teoría general de la prueba y medios probatorios", 3ra. ed. act., pág. 322). Es que determinar la credibilidad y grado de eficacia probatoria de un testimonio constituye un quehacer que debe cumplirse de acuerdo con los principios generales de la sana crítica, atendiendo a la calidad del testimonio (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", Ed. Zavallía, t. 2, p. 248). En tal sentido, el art. 327 del CPC dispone que los tribunales formaran su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Al amparo de tal cartabón, a los efectos de acometer la valoración de un testimonio, debe realizarse un juicio de credibilidad que, como operación mental, debe efectuarse con auxilio de las reglas de la sana crítica, e incluye imprescindiblemente controlar las razones del dicho, tanto [en el] aspecto subjetivo (calidad, fama e ilustración) como por el objeto (contenido del testimonio, razón de la ciencia

del dicho, circunstancia de la percepción y narración, verosimilitud de su exposición y credibilidad que merezcan). En pos de tal finalidad es menester practicar un examen de las condiciones personales del testigo tanto intelectuales, culturales, morales y sociales, como a las relaciones que pueda tener con las partes, de donde se halla incluido el análisis de los móviles internos que son susceptibles de determinar una elusión de lo percibido, tales el parentesco, la afección o aversión y el interés material o moral en que la causa se resuelva en cierto sentido (vide arts. 298, 304 último párr. y 327, CPC). Todos los enunciados, y especialmente lo relativo a la relación con las partes constituyen elementos en los que apoya la "razón del dicho", de necesaria atención para sopesar críticamente el testimonio, y su eficacia probatoria. En caso de resultar una vinculación cercana o proximidad afectiva del testigo con alguna de las partes, se debe encarar la apreciación del medio probatorio con mayor prudencia, lo que es impuesto por las reglas de la sana crítica. Cuando los testimonios son discordantes y con relación a un hecho central brindan contradicciones o ambigüedades, con arreglo a la sana crítica es menester adentrarse en un análisis global que permita identificar la concurrencia o no de puntos de contacto —el conjunto—; además de realizar el análisis individual (calidad del testigo, razones del dicho, contrastación con elementos objetivos de los datos que aporte). Ello permitirá extraer si a alguno de éstos cabe asignarle un mayor valor o una función clarificadora de los restantes; o bien encontrar entre los recabados alguno que brinde un elemento que pueda asirse de una pauta objetiva certera que acreciente el valor de sus dichos. Es que en caso de versiones contradictorias debe preferirse y acordarse mayor valoración a las manifestaciones que reciben apoyo de diferentes elementos de convicción (cfr. Arazi, "La prueba en el proceso civil - Teoría y práctica", Ed. La Rocca, Bs. As. 1986, pág. 260), ya que tal asidero brinda un parámetro objetivo de contrastación de la entidad convictiva y suasoria del testimonio de que se trata. V.c.2) Cuestiona el recurrente la valoración que ha hecho el a quo respecto de los testimonios de los Sres. Amaya, Cuadrelli, Cáceres y El Ain aportados por su parte. En mi visión, la crítica merece acogida. Un detenido análisis de las declaraciones en cuestión me lleva a concluir que no han sido valoradas correctamente por el a quo en su pronunciamiento determinando ello un erróneo acogimiento de la acción. Veamos. A fs. 79 obra la testimonial del Sr. Jose Amaya -de ocupación albañil- quien dijo conocer al demandado por haberle hecho un garaje y trabajos en su casa. Preguntado sobre si en los meses de septiembre y octubre del 2015 realizó trabajos en la casa que se encuentra sito en calle Intendente Oviedo n° 1042 de Mina Clavero-...- dijo "sí le hice trabajos de humedad en su vivienda". Interrogado sobre si fueron trabajos sobre humedades y si las mismas eran muchas (preguntas 5ta. y 6ta.) respondió "sí porque tenían mucha humedad" y "sí eran muchas". Preguntado sobre si a raíz de esos trabajos el Sr. Daniel Resce se fue a vivir de modo temporario a la dirección de Santa Rita 437 y si luego regresó al inmueble dijo "sí estuvo viviendo un tiempo ahí porque si no podía arreglar la casa" y "sí, retornó a vivir a la casa". Este testimonio en mi opinión resulta crucial pues desacredita los dichos del actor en el sentido de que se encontraba en posesión del inmueble en los meses de septiembre y octubre de 2015 y, por ende, que fuera desapoderado por el accionado con fecha 13/10/2015 según manifestara a fs. 2 de la demanda. Se extrae del relato del testigo Amaya que el demandado Daniel Resce le encargó la realización de trabajos de albañilería en el inmueble debido a los problemas de humedad, que ello motivó que aquel alquilara temporariamente en otro lugar con su familia mientras se realizaban las tareas de rigor y que luego retornara a vivir al inmueble. No puedo sino concluir que si el testigo durante el tiempo aludido -meses

septiembre y octubre 2015- realizó los trabajos de albañilería que refirió en el inmueble, ello necesariamente implicó que quien tenía la posesión era el accionado y no el actor. De lo contrario, por una cuestión lógica, el albañil Amaya no hubiera podido concretar aquellas tareas a pedido de aquel en el lapso señalado. No resulta ocioso resaltar que el testigo ha sido claro al referir el tiempo durante el cual realizó los trabajos en el inmueble, dijo "los meses de septiembre y octubre de 2015" es decir que tuvo acceso al inmueble durante ese periodo para hacer su trabajo sin haber manifestado al testificar problema alguno para poder hacerlo. De nuevo, si la propiedad se hubiera encontrado en posesión del actor, el albañil –contratado por el demandado, su hermano y con el cual evidentemente tienen marcadas diferencias– no hubiera podido ni siquiera comenzar con los trabajos encomendados por éste. Por otro costado, el testigo Roberto Enrique Cáceres a fs. 72 ha dicho que conoce al demandado porque es vecino y que "vive" a cincuenta metros de su establecimiento hotelero. Preguntado si le alquila o alquilaba cocheras y desde qué año, dijo que "sí, desde hace seis años, y también llevo el auto a lavar a su lavadero". Asimismo relató que ha visto vivir al Sr. Daniel Resce "desde hace seis años a él y a su esposa" y preguntado si lo ha visto trabajar en la propiedad y desde cuando dijo que "sí, desde la misma fecha hace seis años, en el lavadero y en el estacionamiento". Otro tanto sucede con el testigo Cuadrelli quien dijo haber visto vivir al demandado en el inmueble desde el año 2007 como así también llevarle vehículos y maquinarias para lavar con la lavadora de auto desde el año 2010. Por su parte, el Sr. Alberto Jorge El Ain también manifestó que ha visto trabajar al demandado en el lugar, que tiene allí un lavadero y que desde que lo abrió hace como siete años lleva a lavar su auto allí. También declaró que el accionado vive en el inmueble "desde hace como veinte años". Estos testigos sitúan al accionado y a su familia viviendo en el inmueble objeto del pleito como así también a aquel explotando de manera continua allí un lavadero y alquilando cocheras desde hace varios años. Los testigos aportados por el accionante, Sres. Ary Christian Quinteros -fs. 87- y Aerolinda Lera -fs. 88-, nada trascendente aportan para la solución de la causa. Han dicho básicamente que el demandado vivió con su familia en el inmueble de calle Santa Rita, Barrio Villa Lujan de Mina Clavero hasta octubre de 2015 -ambos- pero sin recordar desde cuándo -el primero-, lo cual fue admitido por el accionado al contestar la demanda (fs. 33). Asimismo y en el caso de la testigo Lera, relató que al retirarse el demandado le dijo que se iba a cortar una cadena porque iba a regresar a una casa que le habían quitado. Con relación a ello entiendo que la mención efectuada por la testigo resulta sumamente vaga e imprecisa. No puede extraerse del dicho ninguna referencia concreta que permita ubicar a dónde el demandado iba supuestamente a realizar el corte de cadenas aludido. Pero, además de ello, encuentro altamente sugestivo que los recibos de alquiler de fs. 7 hayan sido acompañados al proceso por el actor, siendo acreditan una relación locativa entre el demandado y la testigo, cuestión claramente ajena a Juan José Resce. Esta circunstancia, a mi modo de ver, resulta indicadora de cierto grado de proximidad entre la testigo y el actor, lo cual resta credibilidad a lo relatado por aquella en el último tramo de su declaración. En definitiva, las pruebas acompañadas por el accionado reseñadas arriba –sea analizadas individualmente, sea en conjunto–, a mi entender permiten sostener que era éste quien ejercía la posesión sobre el inmueble ubicado en calle Intendente Oviedo 1042 de la ciudad de Mina Clavero al momento del supuesto desapoderamiento denunciado en la demanda, careciendo por lo tanto el actor, Sr. Juan José Resce, de legitimación sustancial activa para llevar adelante la presente acción de despojo. Lo expuesto hasta aquí torna innecesario el tratamiento del resto de las quejas desarrolladas por

el apelante. VI. Consecuentemente debe admitirse el recurso de apelación de que se trata y en consecuencia revocar íntegramente el pronunciamiento atacado, con costas en ambas instancias a cargo del actor vencido, Sr. Juan José Resce (art. 130 del C.P.C.). [...]. El doctor José María Suárez dijo: Que adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Sr. Vocal preopinante, votando en igual sentido a esta única cuestión planteada. El doctor Pablo Alfonso Cabral dijo: I) Coincido con la solución desestimatoria del recurso. En el afán de clarificar la cuestión, es de ver que el accionante afirma ser poseedor del inmueble por ser cesionario de los derechos y acciones emergentes del boleto de compraventa que suscribieran su padre Sr. Alberto Miguel Resce con el titular del mismo Sr. Juan Vadra. La cesión se instrumentó el 15 de agosto de 2014, fecha que solicita se tenga en cuenta para el inicio de la posesión. Sostiene que fue despojado de la propiedad el 11/10/15, mientras se encontraba en la ciudad de Córdoba realizando trámites por el fallecimiento de su progenitor. El juzgador no ha reconocido tal antigüedad en la posesión, se ha limitado a señalar que el actor "poseía la fracción en el tiempo inmediato anterior al hecho interruptor [...] durante el mes de septiembre y parte del mes de octubre de 2015 el inmueble se encontró en posesión del Sr. Juan José Resce, quien lo mantenía cerrado con candado y cadena y lo ofreció para alquilar", apoyando en el testimonio del Sr. Cristian Ricardo Chacón, y luego adiciona que desde octubre de 2015 el Sr. Daniel Alberto Resce no habitaba el inmueble erigiendo el razonamiento sobre el testimonio de los Sres. Quinteros y Lera. Como apunta el apelante, el propio juzgador determinó la nulidad del acta que da cuenta del pretendido testimonio del Sr. Chacón, y ello ya priva de un cimiento trascendente al razonamiento sentencial. Así, sólo puede mantenerse éste en los dichos de Quinteros y Lera, y del repaso de éstos de ninguno puede extraerse que el Sr. Juan José Resce estuviera ocupando a cualquier título el inmueble de autos. Como exponen quienes me preceden, la valoración de los testimonios debe realizarse de un modo integral y no aislado. Y desde tal óptica es revelador que el Sr. Quinteros, en su calidad de vecino del inmueble en disputa, si bien claramente expone que el Sr. Daniel Alberto Resce estuvo en el mismo hasta octubre de 2015 no identifica al Sr. Juan José Resce luego de este hito. Ello sólo enmollece la posición enarbolada por el accionante. Continuando con el razonamiento sentencial, es de ver que en él opera una mutación parcial la razón de hecho señalada por el accionante en su demanda. Allí sostuvo ser poseedor desde el 15 de agosto de 2014, ahora -en los términos de la sentencia cuestionada- sólo lo es durante un mes y medio en septiembre y octubre de 2015. Maguer ello, es claro que quien ocupaba con anterioridad el inmueble y desde hacía seis o siete años lo era el Sr. Daniel Alberto Resce, como surge de los testimonios de los Sres. Cuadrelli (fs. 70), Cáceres (fs. 72), Amaya (fs. 74) y El Ain (fs. 76). Ello también es reforzado por el testimonio del Sr. Quinteros (fs. 87), quien incluso puntualiza que el Sr. Daniel Alberto Resce ocupó el inmueble hasta octubre de 2015, tal como se apuntara supra. Y en cuanto a los meses de septiembre y octubre de 2015, cierto es que el Sr. Daniel Alberto Resce no ocupó la vivienda, trasladándose a residir en un inmueble de la testigo Lera (fs 87 y recibos de fs 7). Mas ello no fue sino porque había que hacerle arreglos por humedades, continuando el Sr. José Eduardo Amaya en la vivienda realizando las obras de albañilería necesarias para la reparación, es decir que el albañil continuó la ocupación ejercida por el Sr. Daniel Alberto Resce realizando en tal condición la obra de reparación en cuestión. En tal sendero, quienes me preceden remarcan la importancia del dicho de Amaya, lo que comparto. En definitiva, la propia posesión por parte del accionante (así lo afirmó en su demanda, más allá se sea suficiente la ocupación como ha puntualizado el juzgador), tal el



primer presupuesto de la acción no se ha acreditado, y de ello sigue que es ocioso demostrar si existe o no despojo. Memórese que de los testimonios de los Sres. Quinteros y Lera nada puede extraerse al respecto. Sólo resta como probanza el contrato de cesión que acompaña, mas si el Sr. Juan José Resce cuenta con derechos emergentes de éste será una cuestión a ventilar por un proceso diverso; maguer ello del mismo y per se de tal instrumento no exuda acreditación de la existencia de una efectiva relación de poder por la cual el Sr. Juan José Resce ejerciera de un modo público sobre el inmueble en cuestión un derecho real. Por tales razones debe recibirse este recurso como proponen quienes me anteceden. Así voto. A mérito del acuerdo que antecede, y por unanimidad; SE RESUELVE: 1) Admitir el recurso de apelación deducido por el demandado, Sr. Daniel Alberto Resce, y en mérito de ello revocar íntegramente la sentencia nº Ciento Tres de fecha 20/11/2020 obrante a fs. 149/159. 2) En reemplazo de la resolución anulada, disponer hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el accionado rechazando la acción de despojo iniciada por el actor. 3) Imponer las costas en ambas instancias al actor vencido, Sr. Juan José Resce (art. 130, CPCC). 4 [Omissis]. Facundo Daniel Gil – José María Suárez – Pablo A. Cabral ♦